

1500763-11.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

" (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500763-11.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500763-11.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234731/2022 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 27038945 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2234731 - 03º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRENTZEN JHONNI PEREIRA PEGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

FRENTZEN JHONNI PEREIRA PEGO, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de agosto de 2022, por volta de 16h45min., na Rua da Bondade, altura do nº 606, Jardim Vista Alegre, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo e tinha em depósito e ocultava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 99 (noventa e nove) porções crack, pesando cerca de 18,0 gramas; 71 (setenta e uma) porções de cocaína, pesando cerca de 49,0 gramas; e 139 (cento e trinta e nove) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por "maconha", pesando cerca de 217,0 gramas (consoante auto de exibição a fls. 14/15 e autos de constatação preliminar de substâncias entorpecentes a fls. 16/21), fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima, para comercializá-la no endereço supramencionado.

Ocorreu que, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo bairro em questão quando, na rua da Bondade, avistaram o indiciado fechando um portão de madeira de um terreno e deliberaram pela abordagem.

Submetido a revista pessoal, em poder de FRENTZEN JHONNI, mais precisamente em sua mão, os agentes localizaram um tubo plástico contendo 18 pedras de crack, 05 porções de "maconha" e 01 "pipeta" de cocaína e, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$50,00 em dinheiro.

Em seguida, os agentes realizaram a busca no terreno de onde o indiciado foi visto saindo, e lá localizaram mais 70 porções de cocaína, 81 pedras de crack e 134 porções de "maconha".

Indagado pelos guardas municipais, o indiciado negou a propriedade das drogas. Interrogado perante a d. Autoridade Policial, FRENTZEN JHONNI negou o tráfico de drogas e admitiu estar na posse de apenas duas porções de cocaína e de duas porções de maconha, para seu consumo pessoal (fls. 10).

Porém, as circunstâncias da apreensão das drogas, a forma de acondicionamento, a quantidade, a variedade, o encontro de dinheiro aliada ao relato dos agentes públicos, evidencia que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado e que se destinavam a entrega a consumo de terceiros.

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2022 (fls. 146), o acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 138/145). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum e interrogando-se o acusado.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência da ação, face a comprovação da autoria e materialidade delitivas, nos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requer que seja desclassificada a conduta para porte de entorpecente para uso próprio, ou, em caso de condenação, que a pena seja fixada no patamar mínimo com regime de pena mais brando e substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, autos de constatação preliminar de fls. 16/21, laudo pericial fls. 97/99, que testou positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), além da prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Ailton Sandrin e Edmilson dos Santos Maria deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro e avistaram o acusado saindo de um terreno baldio, fechando um portãozinho de madeira. Que por se tratar de ponto de tráfico de drogas, resolveram abordá-lo. Ele trazia consigo um tubo plástico contendo 18 pedras de crack, 01 porção de cocaína e 05 porções de maconha e R\$ 50,00. Indagado, disse que era usuário daquela droga. No terreno que ele foi visto saindo, foi feita uma varredura e numa sacola havia mais

70 porções de cocaína, 81 pedras de crack e 134 porções de maconha, embaladas da mesma forma que as porções que estavam com o acusado. Ele negou que estivesse na posse deste entorpecente. Que o acusado é conhecido dos meios policiais, já foi abordado outras vezes neste bairro, em pontos de tráfico de drogas, e dizia que estava na casa de uma tia. Ele não esclareceu sobre a origem do dinheiro. Ele mora em outro bairro. Que não havia mais ninguém com o acusado. Ele estava sozinho naquele local e não acompanhou as buscas no terreno.

O acusado, em seu interrogatório, narrou que naquele dia saiu do trabalho, passou num "chay" e foi para o ponto de tráfico de drogas para adquirir entorpecente. Que comprou duas porções de maconha e duas porções de cocaína de um rapaz, na frente do terreno, e acabou sendo abordado pela guarda municipal. Que o rapaz que estava vendendo a droga fugiu. Que os guardas municipais entraram no terreno vazio e encontraram as drogas. Que desconhece essas drogas. Que a tia mora no bairro, e das vezes que foi abordado, estava na casa dela. Que trabalha como servente de pedreiro.

Em que pese a negativa do acusado, estou convencida de que estava na posse dos entorpecentes para fins de tráfico de drogas, pois os relatos dos guardas municipais são uníssonos, coerentes, seguros e isentos, sendo suficientes para formar a convicção do Juízo.

Não há porque duvidar das alegações destes agentes, pois não se verificou, em nenhum momento, eventual desavença entre eles ou mesmo a intenção destes agentes em prejudicar uma pessoa inocente. E os depoimentos foram firmes e imparciais, e são aptos a ensejar um decreto condenatório, pois nada indica que mentiram em Juízo imputando ao acusado a posse dos entorpecentes falsamente, no caso, as porções de maconha, cocaína e crack, ao contrário do acusado, que tem intenção de apresentar versão exculpatória para livrar-se de uma condenação, ainda que esta seja totalmente inverossímil.

Nota-se que em fase policial o acusado apresentou outra versão para estar naquele local (fls. 07), e não houve nenhuma indicação de uma terceira pessoa no local, que teria fugido ao avistar a viatura, revelando que sua versão foi inventada apenas para tentar se livrar da condenação.

Ademais, os depoimentos destes agentes se mostraram harmônicos e seguros, demonstrando idoneidade, razão pela qual confiro plena credibilidade para firmar meu convencimento.

E a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância do depoimento de guardas municipais, quanto mais se não existe nenhum elemento nos autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

"PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

"PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser

aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

"PROVA. Depoimento policial. Valor. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n.993.08.043553-7, São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal Relator: Newton Neves 09.09.08 V.U. Voto n. 5652).

"PROVA. Depoimento de policial. Validade. Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado. Eficiência. Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva. Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 São Paulo 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal Relator: René Nunes 28.02.07 M.V. Voto n. 10.200).

Ademais, é notório que à configuração do tráfico de drogas não há necessidade da prova da sua venda ou cessão, bastando que o entorpecente seja encontrado com o acusado para se atingir tal escopo, daí porque o fato dele não ter sido visto fazendo a venda ou entregando para alguém em nada altera a adequação típica de sua conduta.

Neste cenário, a alegação de ser mero usuário das porções de maconha, cocaína e crack não se sustenta frente aos elementos de prova colhidos, e o acusado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal condição, na forma do artigo 156 do CPP: "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", não trazendo nenhuma testemunhas para corroborar sua tese.

Nesse sentido:

"TÓXICO - Tráfico - Porte de "tijolinho" de maconha - Quantidade suficiente à confecção de oitenta cigarros - Ônus da demonstração de uso próprio pertencente à defesa - Presunção de destinação comercial - Admissibilidade - Recurso parcialmente provido para outro fim. O agente que, na via pública, traz consigo "tijolinho" de maconha, do qual se pode confeccionar cerca de oitenta cigarros, justifica a presunção de tráfico, sendo inadmissível o acolhimento da alegação de uso próprio sem prova cabal e irrefutável nesse sentido, ônus então da defesa". (Relator: Luiz Pantaleão - Apelação Criminal n. 139.646-3 - Araçatuba - 28.06.93).

"TRÁFICO - Tóxico - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimento dos policiais - Credibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 6.368/76 - Inadmissibilidade - Finalidade comercial evidenciada nos autos - Diversidade (maconha e cocaína), quantidade e forma de acondicionamento que respaldam a tipificação - Crime de natureza permanente que caracteriza-se com o simples fato de trazer consigo a droga - Ausência, ademais, de prova da exclusividade de uso próprio - Ônus da defesa - Sentença confirmada - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 290.772-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal "JANEIRO/2000" - Relator: Debatin Cardoso - 20.01.00 - V.U.).

No mais, o só fato do ser um usuário de drogas, eventual ou compulsivo, não o impede de ser ao mesmo traficante, aliás, tal tipo de comportamento é comum.

Noto que o acusado guardava variadas espécies de drogas: 99 porções crack, 71 porções de cocaína, pesando e 139 porções de maconha, revelando dedicação ao comércio deletério, cuja conduta se adequa perfeitamente ao tipo penal, não havendo

nenhuma causa que exclua o crime ou os isente de pena.

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, do local da abordagem, de espécies variadas e do dinheiro sem comprovação da origem, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, sendo a condenação medida de rigor.

Passo a calcular a pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ré é primário e não ostenta antecedentes criminais. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, o réu comercializava porções de maconha, cocaína e crack, o que vem em seu desfavor, diante da natureza nefasta do entorpecente. A cocaína e o crack são substâncias que causam imediata dependência e exercem um poder devastador sobre a saúde física e mental do usuário bem superior a outras drogas. Os prejuízos e as consequências nefastas destas drogas são constatados diariamente, diante da ampla divulgação, pelos meios de comunicação, dos efeitos maléficos do crack, contribuindo efetivamente com o aumento da criminalidade e destruição de vidas e famílias. A conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade e natureza do entorpecente - aumento a pena de mais 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 680 dias multa. Segunda fase. Ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição de pena, por se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Mas o patamar não será pelo máximo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela quantidade de drogas encontrada em seu poder e variedade, a revelar maior envolvimento com esta atividade. Ora, só quem goza de confiança dos demais membros da organização tem a tarefa de comercializar tamanha quantidade de drogas, o que revela que ele estava integrado neste ambiente odioso. Neste cenário, diminuo a pena de 1/3, totalizando 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 453 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível fixar outro regime que não o mais rigoroso. E no presente caso, considerando que a primariedade do acusado, mas diante das circunstâncias judiciais não lhe serem totalmente favoráveis, em especial pela

quantidade de droga e espécies apreendidas, e por estar inserido num contexto de venda organizada, fixo o regime intermediário para início de cumprimento de pena, até mesmo porque é o cabível à espécie, diante da quantidade de pena fixada. .

Incabível a substituição por penas restritivas de direito, diante da quantidade de pena aplicada. E a respeito do incabimento de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

" (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). Portanto, cometido o crime na sua vigência, indevida a conversão da pena ou a concessão de sursis. 2. Recente entendimento do colendo STF afirma ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, Rel. Min. AYRES DE BRITO); todavia, deve ser ressaltado que foi (a) adotada em sede difusa; (b) por maioria de votos (6x4) e (c) sem efeito vinculante. 3. Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (...). (STJ, HC nº 203.403/ SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, d.j. 21/06/2011).

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Preso em razão do flagrante delito, a Lei nº 11.343/06 veda expressamente a concessão de liberdade provisória para aquele que praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 44). E ainda que assim não fosse, no presente caso se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime de tráfico de drogas enseja habitualidade e solto, por certo voltará a delinquir, até mesmo porque afirmou ser desempregado e sem renda alguma, estando, portanto, a serviço do comércio deletério. Ademais, o acusado se manteve preso durante toda a instrução processual, não havendo fato novo apontando a conveniência da sua soltura.

Ante o exposto, e do que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar o réu FRENTZEN JHONNI PEREIRA PEGO, qualificado nos autos, às penas de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e 453 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e §4º da Lei 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se onde se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Drogas.

Expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA